

1501715-20.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... ostensivo visando combater o tráfico de drogas, abordando suspeitos na rua", que foi exatamente o que aconteceu no caso vertente, no qual os agentes municipais reconheceram que estavam em patrulhamento visando o combate do tráfico. Enfim, por tudo que foi exposto, sendo ilícita a ação que originou a apreensão do entorpecente e a consequente prisão do réu, forçoso reconhecer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501715-20.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2302677/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 3165/2021 -

DEL.SEC.PIRACICABA, 2302677/2021 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIQUE RAFAEL BUENO DOMINGUES

Réu Preso

Contr. nº 2021/001178

Aos 31 de janeiro de 2022, às 16:20 horas, por meio de audiência virtual da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). José Eduardo de Souza Pimentel foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu CAIQUE RAFAEL BUENO DOMINGUES. Presente a Defensoria Pública na pessoa do Dr. Luiz Antonio Felipe Franchito. Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: GM FELIPE VIEIRA ALVES e GM Franscico Dernival Miranda Junior

Antes do início da audiência foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes, (imagem(ns) exibida(s) durante audiência).

Pela M.M Juíza de Direito foi explicado que, diante da restrição de acesso ao prédio do Tribunal de Justiça, em razão da pandemia do COVID-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e orientação do Comunicado CG nº 284/2020, a audiência será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft.

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com o(a) acusad(a) e todos os presentes foram retirados da sala, inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa.

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os

trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s) (Gms Francisco e GM Felipe) e em seguida o interrogatório do réu foi captado e gravado em áudio e vídeo.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a) O réu CAIQUE RAFAEL BUENO DOMINGUES foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 33 da Lei de Drogas. De acordo com a denúncia, no dia 7 de novembro de 2021, por volta das 11 horas, na rua Querubim Sampaio, altura do nº 180, bairro Jardim Planalto, nesta cidade e comarca, o réu, trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 100 eppendorfs contendo cocaína, em pó, com peso bruto aproximado de 126,7 g; 116 porções de cocaína, na forma de pedras de "crack", com peso bruto aproximado de 37g; e 27 porções de maconha (vegetal contendo THC), com peso bruto aproximado de 37,5 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 7). O processo teve trâmite regular, conforme se observa a fls. 108, 112 e 127/128. A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de AEA de fls. 12/13; foto de fls. 14; laudo de constatação de fls. 22/27; laudo do exame químico-toxicológico de fls. 76/78. A autoria também foi determinada na prova oral coligida. Os Gms contaram, em uníssono (na Polícia e em Juízo), que, durante o patrulhamento surpreenderam o denunciado entregando um objeto a um transeunte, em conduta típica de tráfico de drogas. Convictos da prática ilegal, foram ao encontro de CAIQUE e este dispôs 4 pinos de cocaína, posteriormente recolhidos, e empreendeu fuga. O réu foi alcançado e submetido à busca pessoal, resultando da providência o encontro em seu poder de mais 96 pinos contendo cocaína; 116 pedras de "crack"; e 27 porções de maconha; além de R\$ 49,25 proveniente da venda de drogas. O réu admitiu a propriedade das drogas e a destinação ao tráfico. Ao ser interrogado, o réu admitiu o fato. Falou que traficava porque não conseguiu arrumar emprego. Sem controvérsia fática, a condenação é de rigor. À confissão, ajustam-se os depoimentos dos guardas municipais (sobre a validade da palavra dos policiais, cf. TJ-SP - APL: 0000162-52.2013.8.26.0547, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 06/11/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/11/2014). Assim, a condenação é de rigor. No tocante à aplicação da pena, a quantidade e natureza das drogas justificam aumento na primeira fase, pois denota que não estamos diante de traficante ocasional. O réu, entretanto, não possui antecedentes desabonadores (fls. 71). As certidões de objeto e pé de fls. 72 e ss. evidenciam que o réu se dedica ao tráfico desde a menoridade, o que impede a aplicação do privilégio e impõe o regime fechado, sobretudo para coactar a reiteração delitiva e atender às funções da pena privativa. Registro que as testemunhas afirmaram que havia uma escola nas imediações, tratando-se, segundo a pesquisa no Google Maps, de EE Prof. HELIO NEHRING. A mesma ferramenta permite verificar que o local dista 110m do local da abordagem, razão pela qual não aditei a denúncia para fazer constar tal circunstância. Pelo exposto, requer-se a procedência da presente ação penal.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). CAIQUE RAFAEL BUENO DOMINGUES vem processado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, conforme os fatos narrados na inicial acusatória. Após o recebimento da denúncia, a ação penal teve seu regular trâmite e a instrução foi encerrada na presente audiência. Em suas alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. Ocorre, contudo, que a pretensão ministerial não encontra guarida, devendo a ação penal ser julgada improcedente Excelência, inicialmente a Defesa requer seja reconhecida a ilicitude de toda a prova que embasou a presente ação penal. Com efeito, no caso em tela, houve indevida atuação dos guardas municipais, que praticaram atos para os quais não detém competência. Ora, como se sabe, a teor do art. 144, § 8º, da CF, não é tarefa da GCM o policiamento ostensivo, que foi o que aconteceu no presente caso em

que durante patrulhamento os agentes municipais acabaram suspeitando da ação do réu, motivo pelo qual resolveram abordá-los, só então apurando o que realmente acontecia. Isso, aliás, foi declarado pelos guardas municipais que disseram que abordaram o acusado por conta de um comportamento suspeito. Posteriormente, é verdade, houve a localização da droga. Mas isso não torna válido o desvio de função dos agentes municipais. A situação, outrossim, não encontra amparo na primeira parte do art. 301, do CPP, que permite que qualquer do povo efetue a prisão em flagrante. O flagrante na verdade só aconteceu porque muito antes os guardas civis municipais, por conta própria, ampliaram suas atribuições, realizando policiamento ostensivo e investigando possíveis infrações penais, o que é ilegal e inconstitucional. Não há, pois, como dizer que nessa situação, qualquer do povo poderia agir. Afinal, não se vê qualquer do povo perseguindo e revistando terceiros que reputam suspeitos. Nem mesmo fazendo entrevistas. Nessa linha, não há como não considerar que a busca pessoal efetivada é verdadeiro ato investigativo, para a qual os integrantes da GCM, reitere-se, não tem atribuição. A propósito, sobre a busca pessoal, Gustavo Henrique Badaró assim ensina: "Há divergência sobre quem teria atribuição para realizar tais buscas. Não se discute sobre a possibilidade de a autoridade policial, federal ou civil, e de seus agentes realiza-las, até mesmo porque constitucionalmente lhes incumbe a atividade de polícia judiciária (CR, art. 144, § 1º, IV, e § 4º). Por sua vez, no caso de policiais militares, a matéria é controvertida. A polícia militar, embora tenha por finalidade a prevenção ao cometimento de crimes, também tem o escopo de atividade de imediata repressão aos delitos. Assim, não se pode conceber que, na atividade de policiamento preventivo e de imediata repressão a crimes que estejam ou acabaram de ser cometidos, o policial militar não possa, desde que respeitados os requisitos legais, realizar uma busca pessoal, havendo fundada suspeita de que alguém porta um arma ou certa quantidade de droga. Por outro lado, há consenso no sentido de que os guardas municipais não podem realizar buscas pessoais. Por expressa previsão constitucional, cabem-lhes apenas a proteção de bens, serviços e instalações municipais, não lhes sendo atribuída nenhuma função de prevenção ou investigação de crimes". (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 8ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 588). E no mesmo sentido assim decidiu recentemente o C. Superior Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA ILÍCITA. REVISTA PESSOAL REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. ATIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Considera-se ilícita a revista pessoal executada por guardas municipais, sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2. Tendo a busca pessoal ocorrido sem estar o paciente em situação de flagrância, após dias da prática do crime, por guardas municipais que o abordaram sem fundadas razões, apenas por reconhecer sua foto em postagens na rede social comunitária, realizando verdadeira atividade de investigação, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova. 3. Habeas corpus concedido para declarar ilegal a apreensão e, consequentemente, absolver o paciente, nos termos do art. 386, II, do CPP". (STJ - HC 561.329/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020). Em acréscimo, veja ainda que recentemente o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a ilegalidade de uma prisão realizada por guardas civis municipais que incorreram em desvio de função, realizando policiamento ostensivo: "Tráfico de Drogas - Abordagem do acusado em função típica de policiamento ostensivo por guardas civis municipais - Função típica reservada constitucionalmente à Polícia Militar - Não incidência do artigo 301 do Código de Processo Penal - Exorbitância dos poderes atribuídos no artigo 144, § 8º, da Constituição da República Federativa do Brasil - Prova ilícita - Absolvição com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal - Recurso da defesa PROVIDO. & (TJSP Apelação Criminal 1500075-78.2020.8.26.0546; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi Mirim - 1ª Vara; Data do Julgamento: 22/11/2021; Data de Registro: 22/11/2021). Em referido julgado, o i. Desembargador

Heitor Donizete de Oliveira bem explicou que “atento à estrita legalidade, há que se reconhecer que o ordenamento jurídico só permite ao agente público fazer o que estiver expressamente previsto em lei e, assim, no caso concreto, os guardas municipais não estavam autorizados a efetuar patrulhamento ostensivo visando combater o tráfico de drogas, abordando suspeitos na rua”, que foi exatamente o que aconteceu no caso vertente, no qual os agentes municipais reconheceram que estavam em patrulhamento visando o combate do tráfico. Enfim, por tudo que foi exposto, sendo ilícita a ação que originou a apreensão do entorpecente e a consequente prisão do réu, forçoso reconhecer que as demais provas estão contaminadas por tal ilegalidade. Assim, devem ser desconsideradas, de modo que, na falta de provas válidas, deve o acusado ser absolvido, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Caso, no entanto, superada a questão preliminar levantada, a absolvição do acusado pela prática do tráfico, no mérito, é medida que se impõe. Isso porque o que o incrimina é apenas o que foi dito pelos guardas civis municipais, que não podem ser consideradas testemunhas totalmente isentas, tendo em vista que participaram diretamente da prisão do acusado. Sobre isso ainda deve ser considerada a possibilidade de terem atuado de forma contrária às suas atribuições, como já apontado. Assim, é evidente que os servidores municipais tem interesse em justificar seus atos, o que retira o valor probatório de seus testemunhos. Dessa forma, sendo precária a prova produzida, requer-se a absolvição do acusado em razão da falta de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta do réu para a prevista no artigo 28, da Lei de Drogas. Todavia, caso o entendimento de V. Exa seja pela condenação pelo crime descrito na inicial acusatória, a Defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, já que não há qualquer motivo para exasperação, posto que a quantidade de droga não se mostrou excessiva. Além disso, o réu é primário e tem em seu favor as atenuantes da menoridade relativa e confissão (confessou extrajudicialmente e judicialmente). Já na terceira fase, mostra-se possível a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na medida em que estão presentes todos os requisitos legais: o réu é primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nem integra associação ou organização criminosa. Sobre isso, importante destacar que eventuais atos infracionais não podem ser considerados como prova de dedicação a atividades criminosas, conforme vem decidindo a Suprema Corte: A prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Como disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas (arts. 1º e 112) e visam à proteção integral do adolescente infrator”. (Agr no HC 184979/SP, Segunda Turma, Relatora: Min. Carmen Lúcia). “O ato infracional cometido pelo agente quando inimputável não pode ser utilizado como fundamento para se deduzir a dedicação à atividades criminosas, principalmente quando inexistem nos autos provas de práticas delitivas reiteradas.” (HC 179.159, Relator Gilmar Mendes, DJe 19.12.2019).& Na mesma direção já decidiu o STJ: “REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATO INFRACIONAL INDICANDO A RELAÇÃO COM ATIVIDADE CRIMINOSA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para a incidência do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa. 2. In casu, a instância de origem afastou o tráfico privilegiado em razão da prática atos infracionais pelo acusado como forma de indicar a habitualidade criminosa. Entretanto, esse fundamento, por si só, se revela inidôneo, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, impondo a aplicação §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06. 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1172443/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018). E, uma vez operada, a redução, no caso, deve se dar no patamar máximo de 2/3 (dois terços), sobretudo em razão da quantidade de entorpecente apreendida. Por consequência, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por penas restritivas de direitos, na forma do art. 44, do Código Penal, uma vez que se trata

de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e ainda porque a vedação outrora existente já foi declarada inconstitucional pelo STF, tendo o Senado Federal editado Resolução a respeito. Considerando o possível quantum da pena imposta, não há óbice para que seja fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, já que a mera gravidade em abstrato ou seu caráter hediondo – aqui afastado – não justificam a imposição do regime mais gravoso. Caso, todavia, não seja esse o entendimento, tendo em vista que não se vislumbra a possibilidade da pena privativa de liberdade ser estipulada em patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão, requer-se a fixação, ao menos, do regime inicial semiaberto, compatível com a primariedade do acusado. Por fim, requer-se seja deferido ao réu o direito de apresentar eventual recurso de apelação em liberdade. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos,

CAIQUE RAFAEL BUENO DOMINGUES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 7 de novembro de 2021, por volta das 11 horas, na rua Querubim Sampaio, altura do nº 180, bairro Jardim Planalto, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 100 eppendorfs contendo cocaína, em pó, com peso bruto aproximado de 126,7g; 116 porções de cocaína, na forma de pedras de “crack”, com peso bruto aproximado de 37g; e 27 porções de maconha (vegetal contendo THC), com peso bruto aproximado de 37,5g (cf. laudo de constatação de fls. 22/27 e fotografia de fls. 14), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 7). Narra a denúncia que na data indicada, guardas municipais patrulhavam pelo local do fato, conhecido ponto de venda de entorpecentes, quando se depararam com o réu entregando um objeto a um transeunte, em conduta típica de tráfico de drogas (fls. 3 e fls. 4). Convictos da prática ilegal, os servidores públicos foram ao encontro de CAIQUE, e este, ao notar a aproximação dos patrulheiros, dispensou 4 eppendorfs de cocaína que trazia consigo, objetos posteriormente recolhidos, e empreendeu fuga. CAIQUE foi alcançado e submetido à busca pessoal, resultando da providência o encontro em seu poder de mais 96 eppendorfs contendo cocaína; 116 pedras de “crack”; e 27 porções de maconha; além de R\$ 49,25 proveniente da venda de drogas (fls. 12). O acusado confessou a propriedade das drogas e a destinação ao tráfico, o que também foi evidenciado pelas circunstâncias da prisão e quantidade de drogas (fls. 5).

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 108). Defesa preliminar apresentada às fls. 112/119. Após, a denúncia foi recebida (fls. 127/128) e o réu foi citado (fls. 148).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade.

A Defesa pleiteou a absolvição, arguindo ilegalidade na ação dos guardas civis e falta de provas.

É o relatório.

Decido.

Primeiramente, afasto a tese defensiva de que houve ilegalidade na ação dos guardas civis e, conseqüentemente, nulidade da prova.

Os guardas civis integram os quadros funcionais do Município, cujo desempenho básico é a defesa do patrimônio público municipal. Como atuação secundária, cabe aos guardas civis a defesa da população local, compreendida a repressão de atos criminosos danosos aos cidadãos, até porque, caso assim não ajam, respondem na forma do artigo 13, §2º, “a”, do Código Penal, por omissão imprópria, pois têm o dever de agir, na medida em que a lei obriga o dever de cuidado, proteção e vigilância.

Além disso, a preservação da ordem pública é responsabilidade de todos, sendo conferido aos Órgãos de Segurança o dever legal.

Desta forma, é conferida à Guarda Civil a possibilidade de prender quem estiver em

flagrante delito, bem como recolher todos os instrumentos utilizados na prática da infração penal, a fim de que melhor subsidie a apuração dos fatos, nisto incluída a revista pessoal.

Registre-se, ainda, que em 2014 foi sancionada a Lei 13.022/14, que dispõe acerca do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Referido diploma legal institui normas gerais para as Guardas Municipais, disciplinando o artigo 144, §8º, da Constituição Federal. A Lei 13.022/14 constitui norma geral, aplicável a todas as leis municipais que tratem sobre suas respectivas guardas, posto que cada Município deve editar a sua própria lei, adequando-se às disposições do Estatuto Geral das Guardas Municipais. A importância dessa Lei encontra-se no fato de que amplia a restrita interpretação que se havia do artigo 144, §8º, da Constituição Federal. De fato, dispõe esta norma constitucional que "os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei". A interpretação restritiva encontra-se no fato de que as Guardas Municipais sempre tiveram um papel relacionado com a proteção do patrimônio municipal. A Lei 13.022/14 amplia a interpretação, estabelecendo que as Guardas Municipais podem colaborar com os demais órgãos de segurança pública, no caso as Polícias Civil e Militar.

Isso se depreende das competências que a Lei confere às Guardas Municipais. O artigo 4º atribui a competência geral, qual seja, a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município, conforme já previsto na Constituição Federal. Por outro lado, o artigo 5º adjudica as competências específicas. E é entre as competências específicas que podemos destacar que as Guardas Municipais não estão restritas à proteção do patrimônio municipal, mas também lhes são atribuídas funções de colaboração na apuração penal e defesa da paz social.

Outrossim, não cabe qualquer alegação de inconstitucionalidade da Lei 13.022/14, por ter este diploma conferido poderes às Guardas Municipais de atuarem em prol da segurança pública. Em primeiro lugar, as Guardas Municipais integram o sistema de segurança pública do Estado, razão pela qual se encontram em um dos parágrafos do artigo 144, da Constituição Federal. Em segundo lugar, a atuação das Guardas Municipais é sempre ligada às suas atribuições constitucionais (proteção do patrimônio municipal) ou, quando mais ampla, atuará em colaboração com os demais órgãos de segurança pública (Polícias Civil ou Militar). Inclusive, é o que dispõe o artigo 5º, IV e parágrafo único, da Lei. Por fim, as Guardas Municipais, quando no exercício da sua competência, deverão obedecer às competências dos órgãos Federais e Estaduais, prestando o auxílio necessário para a elucidação dos fatos. Pelo que se vê, as Guardas Municipais estão investidas na incumbência de garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de delitos, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência ou, no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso.

Ainda que assim não fosse, não haveria a alegada ilegalidade.

Conforme revelou a prova que a seguir será analisada, o réu foi visto em situação suspeita, típica de tráfico de drogas (parado em conhecido ponto de tráfico entregando algo a uma pessoa e, quando avistou a viatura, evadiu-se, dispensando drogas ao solo) e isso permitiu a ação dos guardas civis.

Registre-se que, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa do povo pode prender em flagrante aquele que está cometendo crime, inexistindo óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais.

Neste sentido, jurisprudências:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO - Preliminar - Nulidade ante a abordagem ter sido realizada por Guardas Civis Municipais - Não ocorrência - Existência de justa causa para a realização da medida - Agentes que possuíam informação a respeito daquele veículo ser utilizado para abastecer o tráfico - Possibilidade para averiguação - Delito permanente, de modo que o acusado se encontrava em situação de flagrante delito - Mérito - Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas - Fala dos agentes firmes e coerentes - Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública - Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu - Quadro Probatório seguro, estando apto a embasar um

decreto condenatório - Pena e regime que não comportam alteração - Preliminar rejeitada e recurso desprovido". (TJSP. Apelação Criminal 1500184-29.2020.8.26.0567. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR EDISON BRANDÃO j. 05/10/2020) g.n.

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE EFETUADO POR GUARDA MUNICIPAL. VALIDADE. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte Superior, é possível que, diante de notícia criminis, envolvendo qualquer dos bens jurídicos mencionados, o agente municipal proceda à atividade de vigilância no local indicado para se certificar de sua veracidade, hipóteses nas quais, de nenhum modo, estaria desautorizado a agir. 2. A situação de flagrância delitiva legitima a atuação de "qualquer pessoa do povo" a proceder à prisão, oportunidade em que é perfeitamente possível a realização da abordagem do suspeito, não sendo diferente em relação àqueles agentes que, ao realizarem seu mister de zelar pelo patrimônio público, muitas vezes se deparam com infrações penais, sendo-lhes lícito atuar em tais ocasiões. Precedentes. 3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 4. O Juiz de primeira instância mencionou fato concreto que evidencia o periculum libertatis, ao salientar que "foi efetuada a apreensão de uma balança de precisão, 01 tijolo de maconha e mais 144 (cento e quarenta e quatro) porções da mesma droga, acondicionadas em pequenas porções, próprias para venda", nos termos do acórdão a quantidade do entorpecente totalizou 782,9g. Ficou registrado, ainda, que o síndico do condomínio, relatou que "Charles Rogério Mendes Júnior é o responsável pela sala de energia, bem como detentor das chaves do local onde foram encontrados os entorpecentes" 5. A adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade das condutas perpetradas (art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar particular periculosidade do acusado. 6. Não se justifica o enquadramento da hipótese na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, por força, mormente, do disposto no art. 8º, § 1º, I, c, que prescreve a excepcionalidade de manutenção da clausura provisória, "em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal", ou caso "as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias". 7. No caso, não há comprovação de que o paciente integra o grupo de risco ou que não esteja inserido em estabelecimento prisional superlotado. 8. Ordem denegada." (STJ - HC 583.610/SP. SEXTA TURMA. Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - j. 04/08/2020) g.n.

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. ART. 301 DO CPP. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE DA DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 630/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe de 20/02/2020; HC 180.365-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 27.03.2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra Carmem Lúcia, DJe de 03/06/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 11.11.2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 17/09/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/06/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro Félix

Fischer, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 03/04/2018. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, inexistente óbice à realização da prisão em flagrante por guardas municipais, por força do disposto no art. 301 do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. 3. Como é de conhecimento, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, constataram a presença da materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, de modo que a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 5. Nos termos do verbete n. 630 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". Assim, na hipótese, não há se falar em incidência da referida atenuante. 6. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 586.612/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA j. 25/08/2020) - g.n.

No mérito, a denúncia procede.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos: boletim de ocorrência de fls. 07/11; auto de exibição e apreensão de fls. 12/13; fotografia de fls. 14; laudo de constatação preliminar de fls. 22/27 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 76/78, os quais atestaram resultados positivos para cocaína e maconha em relação às substâncias apreendidas.

A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 05/06), o réu confessou o crime, dizendo que, na data e horário dos fatos, estava realizando o tráfico de drogas, tendo consigo algumas porções de cocaína que pretendia vender. Após dispensar algumas porções, acabou abordado pelos agentes. As demais porções de entorpecentes localizadas também eram de sua propriedade, mas estavam escondidas num matagal e não na sua posse. Interrogado em juízo (gravação), novamente confessou a infração penal, admitindo a propriedade de todas as drogas e seu destino mercantil.

A confissão foi corroborada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase informativa (fls. 03) e sob o crivo do contraditório (gravação), o guarda civil Francisco Dernival Miranda Junior declarou que na data dos fatos estava com seu parceiro em patrulhamento de rotina e, quando passaram no local em questão, onde há intenso comércio de drogas, viram o acusado prestes entregar algo a uma pessoa, em atitude típica de tráfico. Ao notarem a aproximação da viatura, os dois separaram-se imediatamente sem que o réu tivesse concretizado a entrega e tomaram rumos opostos. O réu dispensou o que tinha em mãos e fugiu. Conseguiram abordá-lo e, com ele, encontraram 96 "pinos" contendo cocaína, 116 "pedras" de crack, 27 "papelotes" de maconha e ainda R\$ 49,25. Foi realizada vistoria no local em o réu estava e ali encontraram os objetos por ele dispensados, tratando-se de 4 invólucros plásticos contendo aparentemente cocaína, em embalagens idênticas as quais estavam com o réu. Ele confessou informalmente que estava realizando o narcotráfico e ainda disse que era o gerente da "biqueira", a qual havia arrendado recentemente por R\$ 4.000,00 mensais. Disse que não conhecia o réu anteriormente, que havia uma escola a menos de um quarteirão do local dos fatos, mas não se lembrou se ela estava em funcionamento nem o nome da escola. No mesmo sentido as declarações prestadas extrajudicialmente (fls. 03) pelo policial civil, o qual acrescentou que já havia apreendido o réu por ato infracional antes dos fatos.

Anoto que os relatos dos guardas civis merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato



administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar suas palavras na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Confirmam-se alguns julgados:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que o réu trazia consigo e possuía, para

fins de tráfico e consumo de terceiros, as porções de cocaína, crack e maconha descritas na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De fato, o acusado foi flagrado pelos agentes no momento em que estava prestes a entregar drogas a um usuário, em um conhecido ponto de venda de drogas, mas ao notarem a aproximação da viatura, ambos empreenderam fuga, sendo o réu detido e encontrado em sua posse a grande quantidade de entorpecentes descrita na denúncia, bem assim mais 4 porções de cocaína que ele dispensou ao fugir.

Além de tal fato ser confirmado pelos guardas em seus depoimentos judiciais, o réu confessou, não só aos guardas, no calor da diligência, mas também perante a Autoridade Policial e em Juízo que as drogas lhe pertenciam e eram destinadas ao comércio.

A expressiva quantidade e variedade de drogas confirmam o destino mercantil, pois incompatíveis com a situação de mero usuário.

Some-se a isso o fato de as drogas estarem embaladas na forma como comumente são comercializadas (fotografia de fls. 14) e de o réu possuir dinheiro que, diante da ausência de comprovação da origem lícita, é evidente que era fruto do tráfico, pois estava em seu poder no ponto de vendas, no momento em que ele estava realizando o comércio ilícito.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

“TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas – Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Mensagens que de whatsapp que não se mostraram o principal para configuração do crime. Apenas se somam aos depoimentos dos policiais. Utilizadas para confrontar o réu no momento da abordagem sobre a prática de tráfico de drogas, este admitiu e indicou onde estaria o restante das drogas. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Não acolhido. Ausência de comprovação de que fosse apenas usuário. De qualquer forma o ser usuário não esbanja a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio vício. Em regra, a paga é em espécie. Dosimetria da pena. Mantida sem alteração. Regime mantido. Não recomendável mais abrandamento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.”

(TJSP - Apelação Criminal 0000106-69.2018.8.26.0603 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - J. 20/07/2020). g.n.

“MATERIALIDADE – Auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – Comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA – Depoimento de policiais que confirma a abordagem da ré e do menor, cujas características coincidiam com aquelas informadas em denúncia como sendo a dos traficantes, ocasião em que houve apreensão de drogas em poder do menor – Confirmação pelos policiais de que o adolescente afirmou que a ré trabalhava junto na traficância, na função de 'olheira' – Validade – Depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – Inocorrência no caso em tela. TRÁFICO – Destinação a terceiros – Quantidade incomum com a figura do usuário – Forma de acondicionamento das drogas, própria para a venda a varejo – Apreensão de dinheiro – Falta de condições econômicas para a ré possuir a droga para seu uso pessoal – Denúncia – De rigor a condenação da ré – Absolvição – Impossibilidade – Negado provimento ao apelo. CAUSA DE AUMENTO – Prática do delito que envolveu adolescente demonstrada pela prova oral – Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. PENA – Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal – natureza da droga de alto potencial lesivo – Manutenção – Presente a atenuante da menoridade – Redução da pena ao mínimo legal – Súmula 231 do STJ – Presente a causa de aumento relacionada com o envolvimento de adolescente – Exasperação da pena em 1/6 – Reconhecido o redutor na fração de 2/3 – Manutenção ante a inércia ministerial – Dedicção da ré à atividade criminosa – Passagem por ato infracional – Apreensão de considerável quantidade de droga – Profissionalização – Dedicção à atividade criminosa – Manutenção porque vedado a

reformatio in pejus - Redução da pena - Impossibilidade - Improvimento ao apelo. REGIME - Fechado - Apreensão de elevada quantidade de droga - Natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo - Alta reprovabilidade e periculosidade - Ré que ostenta processo por ato infracional - O regime deve ser o necessário para dissuadi-los a retornar a delinquir (Beccaria) - Regime fechado - Necessidade - Improvimento ao apelo". (TJSP - Apelação Criminal 1502824-11.2019.8.26.0544 - 6ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Lauro Mens de Mello - J. 16/07/2020).

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06.

Passo à individualização das penas.

O réu é primário e de bons antecedentes.

As demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis. A existência de diversidade de drogas e a quantidade, embora mais expressiva a ponto de indicar o tráfico, não fugiram à normalidade da espécie. Ademais, serão consideradas na terceira fase para, juntamente com outro fundamento, impedir o privilégio.

Assim, fixo as penas-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Não há agravantes.

Reconheço as atenuantes da menoridade e da confissão, mas deixo de diminuir as penas, pois circunstâncias atenuantes não autorizam a redução aquém do mínimo legal.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição das penas.

Não estão presentes os requisitos do parágrafo 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu, embora primário, possui diversas passagens na Vara da Infância e Juventude com condenação por ato infracional equiparado à mesma prática delitiva (processo nº 1500270-35.2019, fls. 96/99 em que sofreu a medida socioeducativa mais gravosa de internação) e por outras práticas delitivas, inclusive ato infracional equiparado a roubo (nº 111-62.2018, fls. 81 em que recebeu a medida de liberdade assistida), o que demonstra que vem se dedicando às atividades criminosas já há algum tempo, desde a menoridade.

Tal fato demonstra que o réu tem total desprezo pela lei e pela justiça e, mesmo depois que atingiu a maioridade penal, continuou se envolvendo em práticas delitivas e traficando.

Não se pode, portanto, equipará-lo aos pequenos e eventuais traficantes, até mesmo em razão da maior quantidade e variedade de drogas que possuía.

Registro que a aplicação da minorante exige a existência cumulativa dos quatro requisitos presentes no dispositivo supramencionado, quais sejam: a) agente ser primário; b) possuir bons antecedentes; c) não se dedicar às atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa o que, aliado ao fato de não ter comprovado exercer atividade lícita e possuir expressiva quantidade e variedade de drogas (quantidade incompatível com os eventuais traficantes) demonstra que vem se dedicando às atividades criminosas, notadamente o tráfico, atividade que vem fazendo como meio de vida.

Conforme exposto acima, não só em razão de condenação anterior por ato infracional de tráfico quando era menor, mas também em razão da expressiva quantidade e variedade de drogas que possuía, e por não demonstrar exercer atividade lícita, o réu não preencheu todos esses requisitos, restando evidenciado que se trata de traficante de maior envergadura e que tem se dedicado às atividades criminosas de forma mais intensa.

No sentido de que, em casos como esse, é incabível o privilégio, já se manifestaram as duas turmas do C. STJ:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006.

INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N.11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. PATAMAR DE ELEVAÇÃO. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. MODO INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE

DIREITO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 3. Assentado pela instância antecedente que o paciente se dedica a atividade delitativa, uma vez que possui medidas socioeducativas em fase de execução, inclusive pela prática de atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, a modificação desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. O registro de atos infracionais é elemento idôneo para se afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes. 5. Segundo posicionamento deste Tribunal Superior, para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária a comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades. 6. Concluído pelas instâncias ordinárias, com fundamento nas provas colhidas nos autos, que a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes ocorreu nas proximidades dos locais previstos no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas, a pretensão de afastá-la demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 7. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima, não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento, em analogia ao disposto na Súmula 443 do STJ, que dispõe: "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". (Precedentes). 8. Hipótese em que o Tribunal de origem majorou a pena na fração de 1/5, tão somente pelo fato de terem sido reconhecidas 2 majorantes (art. 40, III e VI, da Lei n. 11.343/2006), impondo-se, portanto, o redimensionamento para a percentual mínimo (1/6). 9. Fixada a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, sendo primário o réu e favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime semiaberto é